

第2節 控訴

刑事訴訟法
No.306

H18-38 (配点: 3)

月 日
月 日

次の判例（最高裁判所平成16年2月16日第二小法廷判決・刑集58巻2号133頁）の【判旨】中の①から⑥までの（ ）内に後記【語句群】から適切な語句を入れた場合、その組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

【審理経過】

検察官は、「被告人は、平成〇年〇月〇日、H市内において、Vに対し、ナイフ1本を示すなど、兇器を示して脅迫した。」旨の暴力行為等処罰に関する法律違反事件1件（以下、同公訴事実を「本件公訴事実」という。）を起訴した。

第一審は、本件公訴事実について、被告人を無罪とする旨理由中で説示した上、「被告人は、業務その他正当な理由による場合でないのに、平成〇年〇月〇日、H市内において、ナイフ1本を携帯した。」旨の銃砲刀剣類所持等取締法違反の事実（以下「本件犯罪事実」という。）を認定し、被告人を罰金10万円に処し、本件公訴事実には本件犯罪事実の主張も含まれているので、訴因変更の手続は不要である旨判示した。

被告人は、第一審判決中の有罪部分について控訴を申し立てたが、検察官は、控訴を申し立てなかった。

原審は、「本件公訴事実と併合罪の関係にあって起訴されていない本件犯罪事実を認定し有罪の判決をした第一審判決には、刑事訴訟法第378条第3号後段の審判の請求を受けない事件について判決をした違法があるから、破棄を免れない。」旨の弁護人の控訴趣意をいれるとともに、職権調査の結果によれば、本件公訴事実について被告人を無罪とする旨主文で言い渡していない第一審判決には、同号前段の審判の請求を受けた事件について判決をしなかった違法もあると認められる旨判示して、第一審判決中の有罪部分を破棄し本件を第一審裁判所に差し戻した。

これに対し、被告人は、上告を申し立てた。

【判 旨】

原判決が、第一審判決には刑事訴訟法第378条第3号前段及び後段の違法があるとしてこれを破棄した点は正当であるが、本件を第一審裁判所に差し戻した点は、是認することができない。

上記【審理経過】でみたとおり、第一審判決は、罪数に関する法解釈を誤り、①である同号前段及び後段の違法を犯していたのに、検察官は控訴せず、被告人は、本件公訴事実について第一審判決の理由中で無罪とされ不服を申し立てる利益がなかったことから、第一審判決中の有罪部分である本件犯罪事実についてのみ同号後段の違法を理由に控訴を申し立てたが、本件公訴事実、被告人の控訴申立てに伴い、法律上当然に原審に②係属するところとなったのである。このような訴訟の経過にかんがみると、被告人の控訴申立てを契機として、原審裁判所が、職権により本件公訴事実について調査を加え、同号前段の違法がある旨指摘して第一審判決を破棄するにとどまらず、本件公訴事実を③とする余地があるものとして第一審裁判所に差し戻し、あるいは自ら③の判決をすることは、職権の発動の限界を超えるものであって許されないというべきである。そうすると、本件公訴事実については、第一審判決の④の結論に従うほかないのであるから、原審裁判所としては、本件を第一審裁判所に差し戻すのではなく、⑤として被告人に対し④を言い渡すべきであったといわねばならない。

また、本件犯罪事実は、公訴提起がなかったにもかかわらず、第一審裁判所がこれを認定して有罪の判決をしたため、上記控訴申立てに伴い事実上原審に係属するに至ったものであるから、本件犯罪事実については、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効である場合に準じて、

⑥)を言い渡すべきであったと解される。

したがって、原判決は、上記の点において判決に影響を及ぼすべき法令の違反があり、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる。

【語句群】

a. 公訴棄却 b. 免訴 c. 管轄違い d. 移送 e. 移審

f. 有罪 g. 無罪 h. 破棄 i. 自判 j. 差戻

k. 相対的控訴理由 l. 絶対的控訴理由

1. b d f g i k 2. b e f g j k 3. a d f g h k 4. a e f g h l

5. a e f g i l

No306

控訴審

正答率

H18-38

正解

5

43%

() には順に、① = l、② = e、③ = f、④ = g、⑤ = i、⑥ = aが入り、適切な語句は a e f g i l となる。したがって、正解は肢5となる。

本問は、「適切な語句を入れた場合、その組合せとして正しいもの」が問われており、選択肢1から5には、各語句がアルファベット順に並べられている。平成19年第35問のように、「順に並べた場合、正しいもの」が問われているわけではないので、正しい順番で並べられているものは選択肢に無いことに注意が必要である。

なお、完成文は、最判平16.2.16(重判平16刑訴7事件)とほぼ同内容になる。

完成全文

原判決が、第一審判決には刑事訴訟法第378条第3号前段及び後段の違法があるとしてこれを破棄した点は正当であるが、本件を第一審裁判所に差し戻した点は、是認することができない。

上記【審理経過】でみたとおり、第一審判決は、罪数に関する法解釈を誤り、(① l. 絶対的控訴理由)である同号前段及び後段の違法を犯していたのに、検察官は控訴せず、被告人は、本件公訴事実について第一審判決の理由中で無罪とされ不服を申し立てる利益がなかったことから、第一審判決中の有罪部分である本件犯罪事実についてのみ同号後段の違法を理由に控訴を申し立てたが、本件公訴事実、被告人の控訴申立てに伴い、法律上当然に原審に(② e. 移審)係属するところとなったのである。このような訴訟の経過にかんがみると、被告人の控訴申立てを契機として、原審裁判所が、職権により本件公訴事実について調査を加え、同号前段の違法がある旨指摘して第一審判決を破棄するにとどまらず、本件公訴事実を(③ f. 有罪)とする余地があるものとして第一審裁判所に差し戻し、あるいは自ら(③ f. 有罪)の判決をすることは、職権の発動の限界を超えるものであって許されないというべきである。そうすると、本件公訴事実については、第一審判決の(④ g. 無罪)の結論に従うほかないのであるから、原審裁判所としては、本件を第一審裁判所に差し戻すのではなく、(⑤ i. 自判)して被告人に対し(④ g. 無罪)を言い渡すべきであったといわねばならない。

また、本件犯罪事実、公訴提起がなかったにもかかわらず、第一審裁判所がこれを認定して有罪の判決をしたため、上記控訴申立てに伴い事実上原審に係属するに至ったものであるから、本件犯罪事実については、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効である場合に準じて、(⑥ a. 公訴棄却)を言い渡すべきであったと解される。

したがって、原判決は、上記の点において判決に影響を及ぼすべき法令の違反があり、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる。

① l

問題文において、「第一審判決は、罪数に関する法解釈を誤り、(①)である同号前段及び後段の違法を犯していたのに」とされている。そこで、①には、同号すなわち378条3号の内容に関する語句が入る。そして、378条3号は、絶対的控訴理由について規定している。よって、①には「l. 絶対的控訴理由」が当てはまる。したがって、①にはlが入る。

② e

問題文において、「本件公訴事実、被告人の控訴申立てに伴い、法律上当然に原審に(②)係属するところとなったのである。」とされている。そこで、②には、被告人の控訴申立てに伴って生じる効力に関する語句が入る。この点、控訴申立ての効果としては、裁判の確定及び執行が停止される停止の効力と、事件の訴訟係属が上訴審に移る移審の効力とがあり、問題文では「係属する」とされ

ていることから、②は移審の効力についての記述であることが分かる。そして、一部の訴因に対する判断が遺脱してなされた判決に対して上訴があった場合、遺脱訴因についても移審の効力を生ずるか否かにつき、判例は数個の訴因全部について移審の効力を生ずるとしている（最判昭43.4.26）。よって、②には「e. 移審」が当てはまる。したがって、②にはeが入る。

③ f

問題文において、「原審裁判所が、職権により本件公訴事実について調査を加え、同号前段の違法がある旨指摘して第一審判決を破棄するにとどまらず、本件公訴事実を（③）とする余地があるものとして第一審裁判所に差し戻し、あるいは自ら（③）の判決をすることは、職権の発動の限界を超えるものであって許されない」とされている。そこで、③には、本件公訴事実についての第一審判決の結論とは異なる判断に関する語句が入ることが分かる。この点、問題文の【審理経過】をみると、第一審は、主文では言い渡していないものの、「本件公訴事実について、被告人を無罪とする旨理由中で説示し」ており、本件公訴事実については無罪の結論を採っていることが分かる。そうすると、本件公訴事実について第一審判決の無罪の結論とは異なる判断とは有罪であることが分かる。よって、③には「f. 有罪」が当てはまる。したがって、③にはfが入る。

④ g

問題文において、「本件公訴事実については、第一審判決の（④）の結論に従うほかないのであるから」とされ、また「被告人に対し（④）を言い渡すべきであったといわねばならない。」とされている。そこで、④には、本件公訴事実についての第一審判決の結論に関する語句が入る。この点、第一審は、本件公訴事実については無罪の結論を採っている。よって、④には「g. 無罪」が当てはまる。したがって、④にはgが入る。

⑤ i

問題文において、「原審裁判所としては、本件を第一審裁判所に差し戻すのではなく、（⑤）して被告人に対し（④＝g. 無罪）を言い渡すべきであったといわねばならない。」とされている。そこで、⑤には、原審裁判所が無罪判決を言い渡す際になすべき対応に関する語句が入る。そして、原審裁判所が被告事件（本件公訴事実）について更に判決をするのであるから、原判決を破棄自判することになる（400条ただし書）。この点、⑤には「h. 破棄」が入るとも考え得るが、⑤の直前の文章が「本件を第一審裁判所に差し戻すのではなく」とされており、原判決の破棄は前提とされているといえることから、「差戻」に対応する語句である「自判」のほうが⑤に入る語句としてよりふさわしいことが分かる。よって、⑤には「i. 自判」が当てはまる。したがって、⑤にはiが入る。

⑥ a

問題文において、「本件犯罪事実については、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効である場合に準じて、（⑥）を言い渡すべきであったと解される。」とされている。そこで、⑥には、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効である場合になされる裁判に関する語句が入る。そして、条文上「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」（338条4号）には「判決で公訴を棄却しなければならない」と規定されていることから（同条柱書）、公訴棄却が⑥に入るものとしてふさわしいことが分かる。よって、⑥には「a. 公訴棄却」が当てはまる。したがって、⑥にはaが入る。

